Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Crissiumal

Rua Vinte de Setembro, 245 - Bairro: Centro - CEP: 98640000 - Fone: (55) 3524-1610 - Email: frcrissiumvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000253-18.2021.8.21.0094/RS

AUTOR: JANIR ALOISIO BOTH

RÉU: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se ação de obrigação de faze com pedido de tutela antecipada proposta por JANIR ALOISIO BOTH em face de UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA, partes qualificadas.

Alegou a parte autora ser beneficiária de plano de saúde administrado pela parte ré. Afirmou que padece de *NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON – Adenocarcinoma de Cólon D padrão mucinoso, doença classificada pelo CID nº CID C18,* necessitando do uso contínuo do seguinte medicamento: PEMBROLIZUMABE 200 EV A CADA 21 DIAS, até progressão ou toxidade, conforme prescrição médica, sendo que o tratamento lhe foi negado na via administrativa. Asseverou já ter realizado outros tratamento com cobertura pelo plano que não surtiram efeitos, razão pela qual houve a prescrição do medicamento KEYTRUDA (nome comercial). Reclamou, ainda, a gratuidade da justiça, a concessão da tutela antecipada e, ao final, sua confirmação com a procedência da ação. Anexou documentos.

A inicial foi recebida, deferida a gratuidade judiciária e a tutela de urgência (ev. 08).

Citada, a parte ré apresentou contestação (ev. 17). Disse que o fármaco pleiteado não possui autorização, pela Anvisa, para ser aplicado ao quadro clínico apresentado pelo demandante. Discorreu sobre os uso dos Medicamentos Off-label, rol da ANS. Colacionou entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Postulou a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (ev. 17).

Houve réplica (ev. 21).

Aportou aos autos parecer técnico do DMJ (ev. 41).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Impugnação ao valor da causa.

Verica-se que o autor fixou o valor da causa na petição inicial em R$ 676.600,00 (seiscentos e setenta e seis mil e seiscentos reais), considerando o tratamento anual, o que entendo estar adequado. No caso em tela, considerando que não há prazo específico para o término do tratamento médico, o valor das prestações vincendas deve ser igual a uma prestação anual, na forma do § 2° do art. 292 do CPC, *in verbis*:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Logo, tendo sido atribuído à causa valor condizente com o determinado no art. 292, § 2º, do CPC, não merece guarida a impugnação apresentada.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTISMO. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. VALOR INDICADO À CAUSA REFLETE A EXATA ESTIMATIVA ANUAL DO CUSTO DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COBERTURA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. DESCABIMENTO. 1. ***O VALOR A SER ATRIBUÍDO À CAUSA REFLETE A EXATA ESTIMATIVA ANUAL DO CUSTO DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS. CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ PRAZO ESPECÍFICO PARA O TÉRMINO DO TRATAMENTO, A PARTE AUTORA COMPUTOU O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA CALCULAR O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 292, §§1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.*** *2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA DEMANDADA EM RELAÇÃO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA E INCLUSÃO ESCOLAR, UMA VEZ QUE OS RESPECTIVOS TRATAMENTOS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NO COMANDO SENTENCIAL QUE DETERMINOU A COBERTURA DOS TRATAMENTOS DE TERAPIA ABA 30H/SEMANA NA CLÍNICA DE TERAPIA E PSICOLOGIA ABA E DA TERAPIA FONOAUDIÓLOGA 2X POR SEMANA, ASSIM COMO O TRATAMENTO DE MUSICOTERAPIA. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. 3. APLICABILIDADE DO CDC. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 35*

DA LEI 9.656/98, POIS ENVOLVEM TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608 DO STJ. ASSIM, INCIDE, NA ESPÉCIE, O ARTIGO 47 DO CDC, QUE DETERMINA A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ALÉM DISSO, SEGUNDO O PREVISTO NO ART. 51, INCISO IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO PODE IMPOR OBRIGAÇÕES ABUSIVAS QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM. 4. COBERTURA DEVIDA. MOSTRA-SE ABUSIVA A NEGATIVA DA RÉ EM LIMITAR O NÚMERO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE, UMA VEZ QUE CABE A ESTE, CONHECEDOR DAS CONDIÇÕES DO PACIENTE, INDICAR A MELHOR OPÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50496552720198210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-09-2021) (grifei);

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE REGULAMENTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO NEOPLÁSICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. 1. ***Impugnação ao valor da causa: no caso, em que a pretensão é para a cobertura de fornecimento de medicação, com valor certo, prescrita para utilização por tempo indeterminado - enquanto perdurar o tratamento -, incide o disposto no artigo 292, § 2º, do Código de Processo Civil1, devendo o valor da causa corresponder a uma prestação anual. Preliminar afastada.*** *2. Mérito: tratando-se de contrato firmado na vigência da Lei nº 9.656/98, sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo (verbete nº 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça). 3. Segundo prevê a Lei nº 9.656/98, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que apresenta as Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar. 4. Em que pese lícito que a cobertura contratual excetue o fornecimento de tratamento para determinada patologia, quando não prevista em norma regulamentadora da ANS, não se mostra plausível que excetue o fornecimento de medicamento quando evidenciado que a operadora assumiu a responsabilidade pela cobertura da doença que acomete o consumidor. 5. Cabível o fornecimento de medicação para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral, conforme exceção contida no art. 12, inciso I, alínea c, da Lei nº 9.656/98. AFASTARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50213656520208210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 05-08-2021) (grifei);*

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA A PRELIMINAR RECURSAL DA PARTE RÉ DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. APLICABILIDADE DO CDC. PEMBROLIZUMABE. NEOPLASIA MALIGNA DE ENDOMÉTRIO METASTÁTICA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ORA ARBITRADA. ***No que concerne à preliminar recursal de impugnação ao valor da causa suscitada pela parte ré, tem-se que não comporta acolhimento, devendo ser mantido o valor da causa fixado em sentença, equivalente a uma prestação anual, nos termos do artigo 292, § 2º, do CPC*** *Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. No ponto, cumpre salientar que o rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde. Ressalte-se, outrossim, que é facultado aos planos de saúde estabelecerem para quais patologias irão oferecer cobertura; no entanto, não podem limitar o tratamento, pois este cabe somente ao médico assistente do paciente segurado. Precedentes do e. STJ e desta c. Câmara Cível. Reconhecido o dever de cobertura do fármaco neoplásico prescrito pelo médico assistente (pembrolizumabe) para tratamento de neoplasia maligna de endométrio metastática. Tanto a doutrina como jurisprudência sinalizam para o fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais. Dessa forma, não é qualquer descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa, o nexo causal e o dano. No entanto, em situações nas quais o descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais. No caso concreto, a indevida negativa de cobertura levada a cabo pela operadora ré, em desconformidade com a Lei nº 9.656/98, retardou o tratamento de que necessitava a parte autora com urgência, acarretando tal descumprimento contratual situação que ultrapassou o mero dissabor. Arbitra-se o quantum indenizatório em R$ 10.000,00, posto que atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos elementos que devem ser considerados na quantificação, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração das consequências, a condição econômica e o dúplice caráter (compensatório e pedagógico) da reparação. Redimensionamento do ônus da sucumbência e fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da condenação ora arbitrada. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 70082796848, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) (grifei).*

Por conseguinte, vai desacolhida a impugnação.

Do mérito.

Da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor em relação às operadoras de plano de saúde

O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, já afirmou que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, com exceção daqueles celebrados com entidades de autogestão, constituídas com o único objetivo de ofertar planos de saúde a um grupo fechado de beneficiários, sem possuir fins lucrativos.

Nesse sentido é o enunciado nº 608 da Súmula desse Tribunal Superior. Confira-se:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão

No caso, o plano de saúde réu não se trata de entidade de autogestão, de modo que incidem, na espécie, as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Do tratamento mínimo assegurado pelo plano de saúde

A Lei nº 9.656/1998 estabelece as coberturas mínimas a serem oferecidas aos segurados e beneficiários de planos de saúde, previstas nos artigos 10 e 12.

Essas coberturas mínimas podem ser ampliadas, segundo normas estabelecidas pela ANS, autarquia federal para garantia da assistência suplementar à saúde, por força da Lei nº 9.961/2000.

Do cotejo do disposto no artigo 10 da Lei nº 9.656/1998 e do artigo 2º da Resolução Normativa nº 439/2018 da ANS, tem-se presente que as garantias mínimas alcançam todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde.

Daí decorre a conclusão de que, embora seja lícita a limitação das doenças cobertas pelo plano de saúde *(AgInt no AREsp n. 622.630/PE,Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe18/12/2017)*, é defeso a negativa de custeio do tratamento daquelas que não estejam expressamente excluídas no contrato.

Outrossim, conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, é defesa a escolha do tratamento de que necessita o paciente pelo plano de saúde, revelando-se, nesse sentido, abusiva a cláusula limitativa do direito da parte consumidora.

No caso, o autor pretende ver reconhecida a obrigação da operadora do plano de saúde em fornecer o medicamento PEMBROLIZUMABE 200 EV A CADA 21 DIAS

Conforme o laudo médico acostado no Evento 01 - LAUDO 8, emitido pelo Dr. Aníbal Nogueira, especialista em oncologia clínica, o autor é portador de Adenocarcinoma de Cólon D padrão mucinoso, necessitando fazer uso do medicamento KEYTRUDA (nome comercial) até evidência de progressão da doença.

A demandada, por sua vez, alega que não é devida cobertura em questão porque a mediação não é indicada para o tratamento da doença do autor, não estando previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Resolução Normativa n° 465/2021, da ANS.

Todavia, o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já referido. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 608, com o seguinte teor:

Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

Sobre o tema, Karyna Rocha Mendes, Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela ESMP de São Paulo, assevera que (*in* Curso de Direito da Saúde, 1ª ed., Editora Saraiva, 2013, p. 635):

> *(...)*
>
> *Com efeito, nos contratos de prestação de serviço de saúde, como já vimos, as cláusulas que infrinjam os princípios trazidos do Código de Defesa do Consumidor devem ser consideradas abusivas e, consequentemente, desconsideradas do pacto contratual. Nos contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, somente se aplicavam as normas trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação anterior especial aos seguros – num verdadeiro diálogo de fontes.*
>
> *Pelo Código de Defesa do Consumidor temos a aplicação de cláusulas gerais de boa-fé, transparência, informação, normas que buscam o equilíbrio contratual com a proteção da parte vulnerável na relação, o consumidor. O que a Lei nº 9.656/98 fez foi consolidar o que já era considerado abusivo. O espírito do intérprete deve ser guiado pelo art. 7º, do CDC, que autoriza a aplicação de lei e tratados que visem dar ao consumidor maior proteção.*

De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, ainda que não haja previsão em Rol da ANS, que é meramente exemplificativo, ou não atendida eventual diretriz de utilização.

Nesse sentido, *mutatis mutandis*, a recente jurisprudência do STJ:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.*
> *1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).*
> *2. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.*
> *3. Agravo interno não provido.*
> *(AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021);*
>
> *CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO ADMITIDA EM TESE, MAS QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO CASO CONCRETO POR INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO INTERNO*

NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
3. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.
4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp nº 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
Incidência, à hipótese, da Súmula nº 568 do STJ.
5. Conquanto admitida, em tese, a legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, não é possível examinar o tema no caso dos autos, por falta de indicação de qual dispositivo de lei federal foi eventualmente violado, caracterizando deficiência na fundamentação e fazendo incidir à hipótese o teor da Súmula nº 284 o STF, por analogia .
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1691550/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021);

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE NÃO PREVISTO PELO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO E MINORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, o Tribunal de origem considerou que a negativa de cobertura do tratamento ocasionou dano moral pelo fato de ter agravado o sofrimento de paciente que já possuía o "estado anímico combalido pelo diagnóstico de esclerose múltipla", "colocando em risco suas chances em preservar o que lhe restava da capacidade física e mental" (e-STJ, fl. 674). Assim, o acolhimento da pretensão de exclusão do dano moral não prescindiria da aferição das conclusões estabelecidas mediante o reexame direto das provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. Além disso, em conformidade com a jurisprudência do STJ, o quantum arbitrado a título de danos morais está baseado no acervo fático-probatório dos autos, motivo pelo qual somente pode ser revisado nesta instância em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, os quais não observam os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, situação não constatada na espécie em que foram fixados o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1359417/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019).

Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

Afora isso, quando um medicamento é aprovado para uma determinada indicação, não significa que esta seja a única possível. Aliás, na maioria das vezes, o uso *off label* de um medicamento pode ser essencialmente necessário e correto para outras doenças, dependendo tão-somente do entendimento do médico assistente ([1]).

Portanto, a luz do Estatuto Consumerista e da Lei n° 9.656/98, mostra-se abusiva a cláusula contratual que embasou a negativa da cobertura do medicamento prescrito ao demandante.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO (GLIOBLASTOMA MULTIFORME). PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. NEGATIVA FORNECIMENTO MEDICAMENTO. QUIMIOTERAPIA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS IRINOTECANO E BEVACIZUMABE. DESCABIMENTO DA RECUSA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR FÁRMACO PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA O SEGURADO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70055076020, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 28/11/2013);

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. BEVACIZUMABE (AVASTIN). NEGATIVA DE COBERTURA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESCABIMENTO DA RECUSA. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o autor objetiva a condenação da ré a custear o medicamento Bevacizumabe (Avastin), indicado pelo médico que lhe assiste, complementar ao tratamento quimioterápico que está submetido, julgada procedente na origem. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3º, § 2º do CDC e da Súmula 469 do STJ. Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 da referida legislação. Precedentes. Descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária sob a alegação de se tratar de tratamento experimental, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para enfermidade e inclusive para o tratamento prescrito ao autor (quimioterapia) e não a forma como é ele ministrado, cabendo ao profissional da saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento. A busca pela cura da enfermidade do segurado, através de métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, indicados pelo profissional médico que assiste o paciente, deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, inclusive sobre cláusulas que excluam da cobertura securitária fármacos considerados experimentais, as quais se mostram abusivas. Ademais, "in casu", inexiste prova idônea no sentido de que o tratamento prescrito ao segurado pelo médico

credenciado pela ré seja experimental, ônus que incumbia à demandada, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC. Manutenção da sentença que condenou a ré a fornecer ao autor, enquanto perdurar o tratamento referido na inicial, o medicamento Bevacizumabe (nome comercial Avastin), tornando definitiva a tutela antecipada antes concedida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70042485920, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 04/04/2013).

Por sua vez, a conclusão do DMJ também foi favorável ao uso do medicamento, a qual adoto nas razões de decidir (ev. 41). Nesse sentido:

Conclusão CONSIDERANDO a doença da parte autora e o laudo do médico assistente; CONSIDERANDO que o paciente apresenta exame de imunohistoquímica que evidencia presença de anormalidades de expressão das proteínas MSH2 e MSH6 que compõem o sistema de reparo dos erros de pareamento do DNA (MMR – mismatch repair proteins), o que limita a escolha e resposta aos tratamentos; CONSIDERANDO que, atualmente, o medicamento pleiteado já possui registro na ANVISA (12/07/2021) e tem indicação em bula para o tratamento da doença que acomete a parte autora (tratamento de primeira linha em pacientes com câncer colorretal (CCR) metastático com instabilidade microsatélite alta (MSI-H) ou deficiência de enzimas de reparo (dMMR) do DNA), não caracterizando uso off label; CONSIDERANDO que as evidências demonstram maiores benefícios clínicos do tratamento com pembrolizumabe em pacientes portadores de câncer colorretal com deficiência das enzimas de reparo do DNA (dMMR), ou seja, com instabilidade de microssatélites, com aumento na sobrevida livre de progressão de doença; CONSIDERANDO as recomendações das agências internacionais recomendando o uso de pembrolizumabe para pacientes com câncer colorretal metastático e com instabilidade de microssatélites; CONSIDERANDO que a Diretriz da SBOC 202112 aponta o uso de Pembrolizumabe (Nível de Evidência II/Força de Recomendação A) como opção terapêutica em esquemas de 3° e 4° linhas para pacientes com MSI-H/dMMR (caso não tenham recebido imunoterapia previamente); CONCLUI-SE que há elementos técnicos para subsidiar a concessão do fármaco pleiteado à parte autora. Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim Justificativa: Com risco potencial de vida

Ante o exposto, forte no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil de 2015, confirmo a antecipação de tutela e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por JANIR ALOISIO BOTH em face de UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA, partes qualificadas, para condenar a parte ré a fornecer ao autor o medicamento PEMBROLIZUMABE 200 EV, A CADA 21 DIAS, até progressão ou toxidade, conforme prescrição do médico assistente.

Por sua vez, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. De outro lado, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo ou onerar demasiadamente a parte contrária, os honorários serão fixados por apreciação equitativa, conforme § 8º do art. 85 do CPC.

No caso concreto, considerando que o arbitramento sobre o valor da causa R$ 676.600,00 (seiscentos e setenta e seis mil e seiscentos reais) onera demasiadamente a parte ré, tenho que os honorários devem ser fixados em R$ 3.000,00, atualizados pelo IGP-M. considerando o tempo de tramitação do processo e as peças apresentadas.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA**, em 31/5/2022, às 14:30:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10019534132v9** e o código CRC **a0cb4a05**.

---

1. COMO A ANVISA VÊ O USO OFF LABEL DE MEDICAMENTOS: http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=352702&_101_type=content&_101_groupId=33836&_101_urlTitle=como-a-anvisa-ve-o-uso-off-label-de-medicamentos&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DCOMO%2BA%2BANVISA%2BV%25C3%258A%2BO%2BUSO%2BOFF%2BLABEL%2BDE%2BMEDICAMENTOS%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true ↩